

1501062-49.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado LEANDRO RUFINO DOS SANTOS foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha VALDECIR DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, Centro, Cachoeira Paulista - SP - cep 12630-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501062-49.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2331808/2021 - DEL.SEC.CRUZEIRO PLANTÃO, 21802072 - DEL.SEC.CRUZEIRO PLANTÃO,

1026/21/103 - DEL.SEC.CRUZEIRO PLANTÃO, 2331808 - DEL.POL.SILVEIRAS, 1026/21/103 -

DEL.POL.SILVEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO RUFINO DOS SANTOS e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

24/10/2022

Aos 24 de outubro de 2022, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, às 13h30min, na Sala Virtual de Audiências no aplicativo Teams, onde presente se encontrava o(a)MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª Vara desta Comarca, Exmo. Srº Drº. Gabriel Araújo Gonzalez, comigo, Escrevente Técnico Judiciário, a seu cargo, abaixo nomeado, foi aberta, com as formalidades legais, a audiência designada nos autos sob nº 1501062-49.2021.8.26.0621, do Processo Crime que a Justiça Pública move contra LEANDRO RUFINO DOS SANTOS e MAYLON EDUARDO FERREIRA DA SILVA, para audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento. Aberta a audiência por videoconferência, verificou-se a presença do(a) Dr(a). Marcela Agostinho Gomes Ilha, DD. 2ª Promotor(a) de Justiça desta Comarca, as testemunhas e o réu acompanhado de sua advogada Drª Maria de Fátima Damasceno de Paula -Oab/Sp 290.626. Iniciados os trabalhos, às 13h30min, foram ouvidas as testemunhas

arroladas pelo Ministério Público, Valdecir da Silva, Vivian Cristina Boaventura Togeiro, e Maylon Eduardo Ferreira da Silva. Após, procedeu-se ao interrogatório do réu, tendo sido todos os depoimentos prestados gravados em mídia audiovisual. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas, nem requerimentos formulados pelas partes de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal), declaro encerrada a instrução e determino que se passem aos debates orais, o que apresentado pelo Ministério Público e Defesa Técnica, e gravado em mídia audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra LEANDRO RUFINO DOS SANTOS, pela suposta prática do crime do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Na denúncia, narra-se que:

[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo Promotor de Justiça infra-assinado, no uso e gozo de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base no incluso auto de prisão em flagrante, oferecer DENÚNCIA em face de LEANDRO RUFINO DOS SANTOS, qualificado à fl. 05, pelo fato punível que passa a relatar.

Consta do incluso auto de prisão em flagrante que, no dia 06 de dezembro de 2021, às 21h15, na Praça Ten. Anacleto Ferreira Pinto, altura do nº 01, Centro, na cidade de Silveiras, nesta Comarca de Cachoeira Paulista, LEANDRO RUFINO DOS SANTOS trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 23 (vinte e três) Eppendorfs contendo cocaína pulverizada, com peso líquido de 11,93 gramas; substância que causa dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12 e laudo de constatação de fls. 17/19.

Apurou-se que na data sobredita, policiais militares em patrulhamento de rotina divisaram LEANDRO conversando com Maylon. Quando o denunciado ia entregar algo à Maylon, os policiais decidiram pela abordagem, oportunidade em que o Maylon empreendeu fuga, todavia, foi detido.

Em revista pessoal em Maylon, nada foi localizado.

Com LEANDRO, foram localizados 23 (vinte e três) eppendorfs contendo cocaína, bem como R\$10,00 (dez reais), fruto da mercancia ilícita já realizada.

Ao ser indagado, o denunciado confirmou a traficância.[...]

Às fls.49/52, 99/107, 109/119 foram acostados os laudos periciais.

À fl.56, houve a notificação do acusado.

Às fls.80/82, o réu ofereceu resposta à acusação.

Às fls. 86/87, negou-se a absolvição sumária do Réu e foi designada audiência de instrução e julgamento.

À fl.121, houve o recebimento da denúncia.

Em 24/10/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, o MP defendeu que: a ação deve ser julgada procedente; a materialidade foi comprovada; a autoria também foi comprovada; não há razão para não dar credibilidade à palavra policial; a versão do Réu está isolada; o Réu deve ser condenado; não é possível aplicar a redução do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; o regime inicial deve ser o fechado; deve ser apurado o crime de falso testemunho;

Em alegações finais, a defesa afirmou que: o pedido de condenação não deve prosperar; não há provas suficientes para a condenação; em seu interrogatório, o Réu negou que a droga tivesse destinação para terceiros; não há elemento que indique a prática do comércio de drogas; as drogas eram para uso pessoal; deve haver a desclassificação para o art. 28; o Réu deve ser absolvido do art. 33; em caso de condenação, a pena deve ser fixada no mínimo legal, com a redução do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo; o regime incial deve ser o aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, com o direito de recorrer em liberdade; deve haver a restituição do celular.

É o relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da autoria e da materialidade

Cuidam os autos de ação penal pública que visa apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas na modalidade trazer consigo.

Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e os processos como um todo, as questões trazidas a juízo merecem um provimento jurisdicional de cunho material.

O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Na situação ora em apreço, consigne-se, desde já, que a despeito das alegações da defesa técnica, as provas constantes dos autos são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Com efeito, o auto de exibição e apreensão de fls. 15 demonstra que foram apreendidas na posse do Réu 23 porções de cocaína, além de R\$10,00 em espécie. Anote-se que, conforme conclusões do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 19/22, bem como do laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 49/52, verificou-se que são substâncias entorpecentes as matérias apreendidas (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06).

Trata-se precisamente de cocaína, em 11,93g de massa líquida (fls. 20/22).

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado LEANDRO RUFINO DOS SANTOS foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha VALDECIR DA SILVA afirmou que: estava num patrulhamento, com a parceira VIVIAN; perceberam que um dos agentes estava entregando algo para outra pessoa, no meio da praça; achou a situação estranha; na tentativa de abordar, um tentou correr, mas os 2 foram abordados; encontraram 20 e poucos pinos com LEANDRO; os dois foram revistados; com o outro não havia nada; os dois foram ouvidos na delegacia; pelo que viu o Réu informando na delegacia, o Réu falou que estava passando por necessidade financeira, razão pela qual passou a vender a droga; não lembra se os dois foram ouvidos; os dois foram encaminhados para a delegacia de Cruzeiro; os dois foram desembarcados na delegacia da viatura; os dois foram para seccional de Cruzeiro; o Réu mora em Silveiras; conhecia o Réu de vista, mas nunca tinha abordado; conhecia MAYLON de vista; não conhece a mãe de MAYLON; a abordagem foi no anoitecer, mas não lembra o horário; já era noite; presenciou LEANDRO entregando algo (foi isso que chamou a atenção); LEANDRO ficou nervoso quando viu a viatura; o Réu estava entregando algo para o que estava junto na ocorrência (MAYLON); abordaram os dois e conseguiram abordar; o Réu tentou entregar algo, mas não conseguiu quando viu a viatura; ali não costuma ser um local de tráfico de drogas; Silveiras é uma cidade pequena; ficou até o final da ocorrência em Cruzeiro; não consegue dar certeza que os dois foram ouvidos porque faz tempo a ocorrência; o que foi preso com certeza falou; VIVIAN participou da abordagem do começo ao fim.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha VIVIAN CRISTINA BOAVENTURA TOGEIRO afirmou que: estava em patrulhamento com o parceiro; quando entraram na rua de trás da parte, viram os 2 abordados, bem próximos; aparentavam que estavam conversando e que haveria entregar; quando viram a viatura, MAYLON saiu correndo; os dois foram abordados; com LEANDRO, encontraram 23 pinos de cocaína e uma nota de R\$10,00; LEANDRO falou que estava vendendo porque a mãe estava desempregada e ele estava ajudando em casa; os dois foram encaminhados para a delegacia; os dois foram ouvidos na delegacia; já conhecia LEANDRO só de vista; conhecia MAYLON só de vista; conhece a família deles, mas não tem contato; o nome da mãe de MAYLON é PATRÍCIA; nunca tinha abordado MAYLON e LEANDRO; depois dos fatos, MAYLON já foi abordado

mais algumas vezes, em outros locais, mas sem outros fatos parecidos; LEANDRO não chegou a passar drogas para MAYLON (estavam próximos, mas não chegou a passar); a abordagem foi à noite, mas não se lembra o horário.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha MAYLON EDUARDO FERREIRA DA SILVA afirmou que: foram "enquadrados"; não foi ouvido na delegacia; só foi ouvido pelos policiais; mora no endereço indicado à fl. 7; mora em Silveiras, não em Cruzeiro; não mora no endereço indicado à fl. 7; o polícia conhece de Silveiras; não conhece o Delegado JOÃO LUIZ DE BIAZZE; estava com o primo na praça bebendo cerveja; foi abordado por VALDECIR; foi o policial que disse que estava na praça "sem fazer nada"; faz uso eventual de maconha ou cocaína; não disse isso para o policial; é verdade que foram encontradas drogas na bermuda de LEANDRO; LEANDRO não estava vendendo cocaína; não é verdade que foi ouvido na delegacia de Cruzeiro; não foi ouvido na delegacia de Cruzeiro; foi pego com o primo por volta de 21h-22h; nesse dia, estava com o Réu na praça; não sabe se o Réu é traficante; na época do flagrante, o Réu trabalhava; não tem conhecimento se ele vendia droga; o Réu é usuário de drogas; os policiais levaram para Cruzeiro; não chegou a sair da viatura; levaram para a delegacia de Cruzeiro; não chegaram a ficar sozinhos; não lembra quantas drogas tinha com o primo; foi solto e a mãe foi buscar em Cruzeiro; LEANDRO ficou preso; na época, o primo trabalhava; o Réu usava drogas; não sabe o quanto o Réu usava de drogas; o Réu não foi ouvido.

Em seu interrogatório, o Réu LEANDRO RUFINO DOS SANTOS afirmou que: não confirma os fatos; foi abordado pela polícia nesse dia; encontraram cocaína com o Réu; estava com 23 pinos de cocaína; estava com os 10 reais também; estava na praça com o primo; os 23 pinos eram para uso; usa os 23 pinos em um dia e meio; levou a cocaína porque não queria deixar em casa; comprou os 23 pinos de vez; comprou a droga na cidade; usa a droga na rua; anda com essa quantidade para usar; foi encaminhado para a delegacia nesse dia; não lembra do que falou na delegacia; foi perguntado pela polícia civil lá em Cruzeiro; acha que o primo não foi ouvido em Cruzeiro; nega o interrogatório; no dia da abordagem, não foi encontrado nada com MAYLON; não tentaram fugir; na hora da abordagem, não foi revistado; acharam a droga porque o Réu indicou; na época, era usuário de drogas; usava bastante cocaína na época; a abordagem foi por volta das 19h; na delegacia, ficaram umas 2h dentro da viatura; nega que é traficante.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que, na ausência de dúvida razoável sobre a parcialidade dos policiais envolvidos na operação, o seu depoimento é um meio idôneo de prova:

Apelação - Furto qualificado tentado - Condenação - Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato.

(TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara

Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de ausência do laudo de exame de corpo de delito. Crime que deixa vestígios. Nulidade não reconhecida. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investitura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Reincidência descaracterizada. Documento que não traz informação acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa. Pena reduzida ao mínimo legal. Regime inicial de cumprimento abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Restituição de bens e valores apreendidos. Impossibilidade. Objetos que interessam à persecução penal. Incidência dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500083-83.2019.8.26.0548; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (grifos acrescidos)

Os depoimentos colhidos foram coerentes entre si, convergindo quanto aos seguintes fatos: o Réu estava na praça com os entorpecentes encontrados.

Somente destoou o depoimento da testemunha MAYLON, cujo teor foi contraditório: chegou a afirmar que não foi levado a nenhum lugar para depois admitir que foi levado a Cruzeiro (negando que tenha sido ouvido em solo policial), o que foi contrariado pelas outras provas.

Deve-se ressaltar que, diante da multiplicidade de condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação cabal da mercancia, bastando que haja prova da adequação da conduta a qualquer um dos verbos previstos no tipo penal:

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Recurso defensivo buscando a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena, afastando-se o aumento de pena em razão de condenação sem trânsito em julgado para o réu, e mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante - Apreensão de 8,98g de cocaína, na forma de crack – Réu que negou a prática delitiva – negativa que não prospera – Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informação de que o réu retornaria da cidade de Dracena, onde foi comprar drogas para posterior comercialização no Município de Ouro Verde, deslocaram-se até a Rodoviária e aguardaram o retorno dele. Visualizaram o réu descer do ônibus e ele, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer da droga. Realizada a abordagem e indagado, o acusado declarou que a droga destinava-se ao seu consumo próprio. A droga foi localizada, e constataram se tratar de uma porção de crack, que não estava fracionada, e não poderia ser consumida naquele estado, sem antes fracioná-la. Réu que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack – Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no

art. 33, da Lei de Drogas – Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes – condenação de rigor, nos termos da denúncia. Dosimetria – Pena-base fundamentadamente exasperada – Sem alteração na segunda e terceira fases. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal Não cabimento de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado no caso concreto. Recurso da Defesa improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0001325-64.2018.8.26.0168; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifos acrescidos)

Ao contrário do argumentado pela defesa técnica, não é viável a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.

O TJSP tem precedentes no sentido de que não deve haver a desclassificação quando as circunstâncias da conduta indicarem que o agente, surpreendido em posse de drogas, não o fazia para uso próprio:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a desclassificação para o delito o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e a variedade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500579-91.2021.8.26.0597; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão. Parcial razão. Materialidade e autoria indúvidas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apelante flagrado enquanto trazia consigo 07 (sete) eppendorfs de cocaína, com peso bruto de 4,72g (quatro gramas e setenta e dois centigramas) e 01 (um) tablete de maconha, com peso bruto de 500,06g (quinhentos gramas e seis centigramas). Prova oral robusta. Inviabilidade de desclassificação para o uso próprio. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria comporta reparos. Quantidade de entorpecentes apreendida não ultrapassa a normalidade à espécie, devendo manter-se o aumento da basilar apenas com relação aos maus antecedentes, na fração de 1/6 (um sexto). Comprovada reincidência. Impossível a concessão do privilégio. Não preenchimento dos requisitos legais. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500181-14.2021.8.26.0123; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022) (grifos acrescidos)

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Recurso da defesa - Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Conduta criminosa verificada a partir das circunstâncias da prisão em flagrante – Suposto usuário de drogas admitiu na fase inquérito que o acusado lhe vendeu parte da droga apreendida – Desclassificação para o artigo 28 da Lei Drogas – Impossibilidade – Contexto fático não sugere que a droga seria para o consumo do acusado, mesmo porque 4 porções de cocaína foram apreendidas na posse de terceiro, após o acusado tê-las vendido – Presentes os requisitos do "privilégio" (§ 4º do artigo 33 da Lei de Drogas), deve a diminuição de pena ser feita na fração máxima (2/3) – Inviabilidade de se operar a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como

modificar o regime semiaberto, porquanto, no curso desta ação penal, o acusado foi condenado outras duas vezes pelo mesmo crime – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501281-78.2020.8.26.0530; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022) (grifos acrescidos)

No caso concreto, o fato de ter sido encontrado com 23 pinos de cocaína, numa praça pública, indica que a conduta do agente não se amolda ao art. 28 da Lei de Drogas, de sorte que é inviável a desclassificação pretendida.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu LEANDRO RUFINO DOS SANTOS, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto a culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o Réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o Réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu LEANDRO RUFINO DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: tratam-se de acusados sem antecedentes criminais na forma da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderá ser considerada negativa; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida dos acusados em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade dos réus, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: visando não incidir em bis in idem serão valoradas apenas na terceira fase da dosimetria.

Assim, diante da ausência de circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravantes a reconhecer.

No caso concreto, tendo em vista que o agente confessou a posse da droga, mas afirmou que ela se destinava a uso pessoal, não é possível aplicar a atenuante da confissão:

Súmula 630 (STJ). A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Desta forma, não aplico a referida atenuante.

Por isso, a pena-intermediária é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Quanto à terceira-fase, é preciso enfrentar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, que exige a presença de quatro requisitos para a diminuição da pena: a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) ausência de dedicação a atividades criminosas; d) não integração de organização criminosa.

Em sede de julgamentos de recursos especiais repetitivos (Tema 1139), o STJ fixou tese no sentido de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

Desta forma, só é possível afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas se: a) houver maus antecedentes, inclusive por fato anterior à presente imputação, mas com trânsito em julgado posterior ao presente processo; b) houver reincidência; ou c) as circunstâncias do caso concreto (não outros processos) indicarem que não se trata de uma conduta pontual ou iniciante e que há efetiva dedicação a atividades criminosas ou pertencimento a organização criminosa. No caso concreto, não há prova de nenhuma das hipóteses acima, de sorte que entendo que é possível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Com relação à fração de diminuição, já que o dispositivo prevê uma margem de 1/6 a 2/3, a doutrina sugere a utilização dos critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas:

"91-C. Critérios para a diminuição da pena: o legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. Cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei: 'o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente'" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, vol. 1, p. 424) (grifos acrescentados)

Considerando a apreensão de droga da espécie cocaína e em quantidade expressiva, sobretudo se considerada a traficância ordinária da região, a pena intermediária deve ser diminuída na fração de 1/2, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Impede salientar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo serem observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto.

Assim, nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena.

Considerando, entretanto, que o Réu preenche os requisitos do art. 44, I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a prestação de serviços à comunidade, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP), e a prestação pecuniária de 01 (hum) salário mínimo, a serem pagos a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do CP).

Incabível a sua suspensão condicional, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o Réu LEANDRO RUFINO DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06 às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto e ao pagamento de 250 dias-multa no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando, entretanto, que o réu preenche os requisitos do art. 44, I a III, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP, e a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA de 01 (hum) salário mínimo, a serem pagos a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do CP).

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO os sentenciados ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva dos réus por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com relação à restituição do celular, aguarde-se o trânsito em julgado.

Quanto ao suposto falso testemunho, desnecessário adotar qualquer medida, já que o MP tomou ciência do fato no decorrer da audiência, podendo tomar as medidas que entender cabíveis.

Considerando a demonstração de que o dinheiro apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos valores apreendidos e depositados. Some-se a isso o fato de que O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017).

Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia e do bem em favor do FUNAD.

DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresse acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções criminais.

COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação",

arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006), caso a providência já não tenha sido adotada.

Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O Ministério Público, a Defesa e réu informam que irão recorrer da presente.

Desde já dê-se vista ao Ministério Público e à Defesa para apresentação de razões e, após, de contra-razões.

Providencie a z. serventia a juntada aos autos do link da audiência realizada nestes autos, para posterior acesso pelas partes. Nada mais havendo, às 14h28min foi encerrada a presente audiência com as formalidades legais. Do que, para constar, lavrei este termo, o qual vai assinado digitalmente apenas pelo(a) MM(a). Juiz(a), nos termos dos arts. 1269 e 1270 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, Tomo I. Eu, Rosângela da Silva Fortunato Teixeira, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei.

MM(a). Juiz(a): (assinado digitalmente)